

第 32 問

甲は、かねて顔見知りのA女（20歳）を強いて性交しようと企て、自宅まで送ってやると言って、同女を自分の車に乗せた。途中で方向の違うことに気付いたA女が「降りして。」と頼んだが、甲は、かまわず車を疾走させた。人気のない山中に着くと、甲は、強いて性交する目的でA女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした。極度に畏怖したA女は、「お金をあげるから勘弁して。」と言って現金3万円入りの財布を差し出した。甲がこの財布をA女から取り上げ、中身を調べているすきに、A女は逃げ去った。

甲の罪責を論ぜよ。

（旧司法試験 平成2年度 第2問 改題）

第1 A女を車に乗せ、疾走させた行為について

1 わいせつ目的誘拐罪（225）は問題なく成立する。

監禁罪（220）の成否については、A女が「降ろして。」と甲に頼んだ時点以降に成立するのか、同女を車に乗せ、車を発進させた時点から成立するのかが問題となる（**論点** 逮捕・監禁罪の保護法益  司H25,旧H2-2）。

この点について、いわゆる現実的自由説からはA女が「降ろして。」と甲に頼んだ時点以降（ただし、被害者の承諾が錯誤によって無効となる可能性がある）、可能的自由説からは、A女を車に乗せ、車を発進させた時点から成立する。

2 罪数処理として誘拐罪と監禁罪の関係が問題となるが（**論点** 監禁罪と略取（誘拐）罪の関係）、判例（最決昭58.9.27）には、身代金目的拐取罪と監禁罪について併合罪（45前段）としたものがある。

 総合 175 頁  論証 72 頁

 65 頁

第2 A女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした行為について

遅くとも、強いて性交する目的でA女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした時点で強制性交罪（177）の実行の着手（43本文）が認められるから、強制性交未遂罪（180、177）が成立する。

第3 A女から財布を受け取った行為について

甲が財布を奪取する意思を生じたのは、A女が財布を差し出した時点だろうから、強盗の故意の有無が問題となる（**論点** 事後的奪取意思  司H28,R2,旧H2-2,H6-2）。

この点については、新たな暴行・脅迫があり、これを強盗罪の実行行為としての暴行・脅迫と評価することができる場合には、強盗罪（本問では、強盗・強制性交等罪（241 I））が成立するという立場が一般的である（大阪高判平元.3.3、東京高判平20.3.19【百選Ⅱ42】）。

甲がこの財布をA女から取り上げ、中身を調べるといった行為が、新たな暴行・脅迫に当たるとみるか否かで強盗・強制性交等罪が成立するか、窃盗罪（235）が成立するかが変わる。

 総合 205 頁  論証 88 頁

答案構成

第1 A女を車に乗せ、疾走させた行為について

1 わいせつ目的誘拐罪（225）成立

↓

2 監禁罪（220）の成立時点

↓

可能的自由説

↓

甲が同女を車に乗せ、車を発進させた時点で監禁罪が成立する

↓

3 両罪は併合罪となる

第2 A女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした行為について

1 強姦性交等罪（177）の「実行」の「着手」（43本文）が認められる

↓

2 同罪は未遂（180、177）にとどまる

第3 A女から財布を受け取った行為について

1 強盗・強姦性交等罪（241 I）の成否

↓

2 事後的奪取意思

↓

原則として、強盗罪は成立しないが、新たな暴行・脅迫があれば、強盗罪は成立する

↓

3 あてはめ

第4 罪数

甲に、わいせつ目的誘拐罪、監禁罪、強姦性交等未遂罪、窃盗罪が成立し、全て併合罪となる（45前段）

第1 A女を車に乗せ、疾走させた行為について

1 まず、甲は、A女を強いて性交しようと企て、自宅まで送ってやると偽って、同女を自分の車に乗せ、車を発進させている。この甲の行為は、「わいせつ……の目的」で、詐欺を手段として「人」を不法にその生活環境から離脱させて、行為者自身の実力的支配内に移しているといえるから、「誘拐」したものとして、わいせつ目的誘拐罪（225条）が成立する。

2 次に、遅くともA女が「降ろして」と甲に頼んだ時点以降は、「不法に人を……監禁した」として、監禁罪（220条）が成立する。では、それより前の時点、すなわち、甲が同女を車に乗せ、車を発進させた時点で監禁罪が成立しないか。

「監禁」とは、人を一定の場所から脱走できないようにしてその身体活動の自由を奪うことをいうが、A女は自宅に送ってもらえると誤信しており、現実に移動しようという意思を有しない。

この点に関して、監禁罪の保護法益を現に移動しようと思って移動できる自由（現実的自由）と捉える見解がある。この見解によれば、A女は現実に移動しようという意思を有しない以上、A女が甲に下車を依頼するまでの間は、監禁罪は成立しないこととなる。

しかし、被害者がたまたま移動の意思を起こすか否かで、犯罪の成否が左右されることになるのは妥当ではない。身体活動の自由とは、移動したいときに移動できる自由というべきである。

したがって、客体の有する自由の程度は潜在的・可能的自由で足り、

1

本罪の客体たるために具体的な行動の意思は必要ないというべきである。

本問では、甲が同女を車に乗せ、車を発進させた時点で、甲女の潜在的・可能的自由が害されており、人を一定の場所から脱走できないようにしてその身体活動の自由を奪っているから、その時点で「監禁」したといえ、監禁罪が成立する。

3 では、上記の誘拐罪と監禁罪の関係をいかに解すべきか。

略取・誘拐行為を構成する暴行・欺罔・脅迫・誘惑自体は継続していない。また、被拐取者の引渡し、收受等に関する罪が別途規定されている（227条）ことから、略取・誘拐罪は継続犯であるとはいえない。

したがって、略取・誘拐罪は状態犯であると解すべきである。

一方で、監禁罪は継続犯であるから、「一個の行為が二個以上の罪名に触れ」（54条1項前段）する場合であるとはいえない。

また、両罪の間に罪質上通例手段結果の関係が存在するとも言い難いから、「犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる」（同項後段）ともいえない。

よって、両罪は併合罪（45条前段）の関係に立つと解する。

第2 A女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした行為について

1 次に、遅くとも、強いて性交する目的でA女を無理やり車外に引っ張り出し、押し倒そうとした時点では、被害者の反抗を著しく困難にする

2

程度の不法な有形力を行使し（「暴行」）、「13歳以上の者」に対して「性交」しようとしたものとして、強制性交罪（177条）の「実行」の「着手」（43条本文）が認められる。

2 もっとも、最終的に、A女が逃げ去ったことから、甲は目的を達していない。したがって、「これを遂げなかった」ものとして、同罪は未遂（180条、177条）にとどまる。

第3 A女から財布を受け取った行為について

1 続いて、極度に畏怖したA女が「お金をあげるから勘弁して。」と言って現金3万円入りの財布を差し出したところ、甲がこの財布をA女から取り上げた点について、「強制性交等の罪……を犯した者が強盗の罪……をも犯した」ものとして、強盗・強制性交等罪（241条1項）の成立が考えられる。

2 しかし、強盗は暴行・脅迫を手段として財物を奪取する犯罪であるから、強盗が成立するためには、財物の強取に向けられた暴行・脅迫が必要であり、事後的に財物の奪取意思を生じた場合は、強盗は成立しないのが原則である。

一方で、財物奪取の意図が生じた後に新たに暴行・脅迫があれば、上記関係及びその認識が認められるから、強盗としてよい。

3 本件では、甲は、強いて性交する目的で、A女を無理やり車外に引き張り出し、押し倒そうとしており、この時点では、強盗における「暴行」には当たらない。また、既に極度に畏怖しているA女が差し出した財布を取り上げたにすぎず、この点について新たな暴行・脅迫は認めら

3

れない。

したがって、甲に強盗は成立せず、強盗・強制性交等罪も成立しない。

以上から、甲には「他人の財物を窃取した」ものとして窃盗罪（235条）が成立するととどまる。

第4 罪数

甲に、わいせつ目的誘拐罪、監禁罪、強制性交未遂罪、窃盗罪が成立し、全て併合罪（45条前段）となる。

以上

4